

1500060-70.2021.8.26.0580

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE FIGUEREDO SAULLO

Comarca: Cândido Mota

Foro: Foro de Cândido Mota

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... sabia de envolvimento do filho com o tráfico sabendo que ele era usuário e jamais esperava que o filho mexesse com o tráfico e acredita que foi a primeira vez que isso aconteceu porque ele não demonstrava esse envolvimento e sempre trabalhava junto com a família. Moram em Cândido Mota há 12 anos. Em nenhum momento os policiais os ameaçaram. O réu trabalhava com a família ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cândido Mota

Foro de Cândido Mota

2ª Vara

Praça Antonio Pípolo, s/nº, Candido Mota - SP - cep 19880-000

1500060-70.2021.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500060-70.2021.8.26.0580

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PERICLES FREITAG BENITEZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE FIGUEREDO SAULLO

Vistos.

PERICLES FREITAG BENITEZ, qualificado nos autos (p. 05), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de fevereiro de 2021, local e horário descritos na denúncia, mantinha em depósito drogas, consistentes em 88 (oitenta e oito) porções de cocaína, pesando 36,94g (trinta e seis gramas e novecentos e quarenta miligramas) e 47 (quarenta e sete) porções de maconha, pesando 75,65g (setenta e cinco gramas e seiscentos e cinquenta miligramas), destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular (p. 69-70).

O réu foi notificado (p. 95-99) e apresentou defesa prévia, pugnando pela rejeição da denúncia por ausência de justa causa diante da ilicitude da prova e flagrante ilegal (p. 95-99).

Denúncia recebida (p. 118-119) e o réu foi citado para audiência (p. 132).

Durante a instrução processual procedeu-se à oitiva de 02 testemunhas de acusação e 02 testemunhas de defesa e o réu foi interrogado, manifestando-se o Ministério Público em memoriais, pugnando pela condenação do acusado (p. 246-254); enquanto que a defesa se manifestou em alegações finais por memoriais, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas (p. 258-265).

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01-

04), boletim de ocorrência (p. 05-07) pelo auto de exibição e apreensão (p. 08), acompanhado de fotografias (p. 18-21), pelo laudo de constatação provisório (p. 26-28) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo n. 53.456/2021 (p. 199-201), acusando resultado positivo do material apreendido para "Cocaína" e Tetrahidrocannabinol (THC), substâncias proibidas pela Portaria 344/1998 SVS/MS. A autoria não é menos, mormente considerando a prova oral.

A testemunha em de acusação, Luis Rodrigo Garcia, policial militar, ouvido em juízo, disse que: "Estava de serviço pela Força Tática como Cabo Santili quando um indivíduo parou os parou e informou, noticiando o endereço e o nome do réu, dizendo que o réu armazenava e vendia droga no local. Disse ainda que o réu armazenava uma arma, mas o delegado não quis contar isso no depoimento. No local encontraram os pais do réu que inconformados com o teor da informação autorizaram a entrada na casa e no quarto do réu foi encontrado dentro de uma escrivaninha 02 porções de maconha embaladas para venda. Em entrevista o réu disse que tinha mais droga e os levou nos fundos do quintal nos pés de uma bananeira com dois sacos plásticos contento o restante de porções de maconha em um dos sacos e no outro as porções de cocaína. O réu disse que o fornecedor da droga era da Andirá e vinha com uma Parati branca, dizendo ainda que entrou no negócio para tirar a habilitação. Não conhecia. A droga estava na escrivaninha, acredita que dentro da gaveta, não se recordando ao certo, sendo que foi o parceiro quem retirou essa droga. Os pais do réu estavam fazendo pão que disseram comercializar e ficaram indignados com a conduta do réu dizendo que não foi essa educação que o deram. Era um quintal extenso com 40 metros de comprimento nos fundos da casa onde foi encontrada a droga no local indicado pelo réu. Não conhecia o local e a residência do réu nunca foi indicada em ocorrência anterior. O réu foi algemado para evitar risco de fuga. O depoente com os demais policiais conversaram com os pais do réu que inclusive assinaram uma declaração para ingresso na residência" (p. 151)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de acusação, Rafael Santili, policial militar, ouvido em juízo, dizendo que: "Estavam em patrulhamento na cidade quando receberam a denúncia indicando o nome do réu que armazenava e comercializava drogas na sua residência além de uma arma de fogo. Passaram o endereço e no local foram recebidos pelos genitores do réu, informando-os sobre o motivo da presença e de pronto os genitores autorizaram o ingresso dos policiais. O réu estava no quarto e a princípio negou que tivesse droga sendo encontradas duas porções na residência dele e indagado ficou muito nervoso e foi algemado para não fugir. Depois admitiu que tinha mais droga e indicou o local nos fundos da residência onde localizaram um pacote contendo o restante das porções de maconha embaladas de forma idêntica às do quarto e mais um pacote com as porções de cocaína. Não foi encontrado arma. O réu disse que recebia a droga de um rapaz de Andirá em uma Parati branca e que ele se envolveu com o tráfico para pagar a CNH. Não conhecia o acusado e nem o local do fato. Foi o depoente quem encontrou a droga em uma gaveta em uma escrivaninha. A mãe do réu ficou muito mais nervosa sendo que no momento que achou a droga ela ficou apreensiva com a situação. O pai foi mais compreensivo, e foi possível notar que os pais são trabalhadores, não compactuam com a conduta do filho e não tinham conhecimento do que ele fazia dentro de casa. A denúncia foi feita diretamente à equipe por uma pessoa que chegou até a viatura policial e passou a informação mas não foi identificada para evitar represálias. Quando chamaram os genitores do réu atenderam juntos e acompanharam junto os policiais até o quarto onde o réu estava e acompanharam todas as buscas. O réu estava acordado no quarto dele quando entraram e onde a própria mãe havia indicado" (p. 150)

A testemunha de defesa, Heitor Carlonga Benitez, ouvido em juízo, disse que: "Estava lavando o carro quando a polícia chamou no portão e foram recebidos pelo depoente confirmando que tinha o filho e que ele estava em casa. Pediram para conversar com ele e o depoente autorizou dizendo que iriam esperar o réu. No que abriu o portão os policiais entraram sem que o depoente soubesse que estava acontecendo. O réu sempre foi um filho obediente. Ficou surpreso com a situação porque nunca aconteceu antes. Sobre o motivo da presença dos policiais ali eles nada disseram e apenas foi chamar o filho que estava dormindo. Os policiais entraram junto dentro de casa pediram para a esposa do depoente que disse que iria

chamar o réu que estava dentro do quarto. A esposa do réu foi ao banheiro achando que o filho estava lá e quando saiu os policiais já estavam no quarto chamando o réu. O depoente ficou aguardando conversarem com ele, revistaram o quarto onde dormem sendo que tem um único quarto onde o filho estava deitado no momento. Ficou esperando o resultado da revista quando os policiais encontraram o entorpecente nos fundos do quintal. Dentro de casa nada foi encontrado. Depois de revistarem o quarto os policiais nada disseram ao interrogado. Acompanhou os policiais até os fundos da casa, sendo que foram 03 policiais até os fundos e os demais ficaram na guarda na área ao lado de fora de casa e o réu ficou no quarto conversando com um dos policiais. Nos fundos da casa fizeram a vistoria e encontraram a droga lá debaixo de umas folhas de bananeira e mostraram que haviam dois pacotes de entorpecentes escondidos no local. Ficou surpreso com a situação. O que falou com o réu foi que o ama e acredita o que quis ensinar a ele durante toda a vida dele. Acredita que Deus vai o abençoar e que ele vai se recuperar. Não conversou com o filho sobre a droga. Não sabia de envolvimento do filho com o tráfico sabendo que ele era usuário e jamais esperava que o filho mexesse com o tráfico e acredita que foi a primeira vez que isso aconteceu porque ele não demonstrava esse envolvimento e sempre trabalhava junto com a família. Moram em Cândido Mota há 12 anos. Em nenhum momento os policiais os ameaçaram. O réu trabalhava com a família assando e fazia a produção de pães em casa" (p. 148).

A testemunha de defesa, Clarice Vilma Freitag, mãe do réu, ouvida em juízo como informante, disse que: "Quando o policial entrou a depoente estava na cozinha e viu quando ele passou pela janela e foi conversar com ele que disse que gostaria de conversar com o réu. Pediu que o policial esperasse e quando foi chamar o policial já estava dentro do quarto dizendo que gostaria de conversar com o réu dentro do quarto. Nesse momento o policial disse que tinham recebido uma denúncia do réu que estava guardando drogas dentro de casa. A depoente disse que jamais aceitaria isso dentro da casa. O policial disse que a conversa era de homem com o réu e que se ele não entregasse os pais iriam juntos. Revistaram dentro da casa e com cachorro e não localizaram nada. Entrou em desespero e foi ligar para o advogado. Quando o réu disse que tinha essas coisas e os policiais foram nos fundos para pegar a depoente foi ligar para o advogado. O réu disse que tinha guardado lá nos fundos, e os dois policiais foram nos fundos. Acredita quem eram uns 06 policiais em casa. Foi o marido da depoente que foi aos fundos com os policiais. Quando ele disse onde estava a droga eles o algemaram e levaram ele para fora de casa, lá para trás nos fundos da casa, mas a depoente não foi junto. O esposo da depoente foi junto com os policiais e o réu nos fundos do quintal. Não sabe o que aconteceu nos fundos do quintal. Quando saíram dos fundos o marido da depoente e os policiais disseram terem encontrado a droga nos fundos da casa. Sabia que o réu era usuário, mas não sabe de qual droga. O réu trabalhava com a família como ajudante da depoente sendo quem assa as coisas e ajuda na produção. O réu tem profissão de pintor" (p. 148). Interrogatório em juízo, o réu negou os fatos, dizendo que: "Não vendia droga. Pegou a droga para uso próprio. Foi em um cara em Andirá para pegar no carão com ele. É usuário químico desde os 14 anos e os pais não sabiam, achavam que usava só maconha. Foi para pegar o carão e o fornecedor disse que só tinha embalado nesses dois pacotes de droga. O de cocaína tinha 100 pinos e o de maconha tinha 60 porções. A droga era para uso próprio e nunca pegou para vender. Não gosta de traficante porque é a causa de outros crimes com os quais nunca quis ser conivente. Usava a droga dentro do terreno e ficou surpreso sobre a denúncia anônima que fizeram sobre sua pessoa sendo que ninguém sabia. Tinha acabado de colocar os pacotes em casa. Tinha chegado em casa às 14:30 horas já lúcido, ajudou a mãe e foi dormir quando às 16:30 terminou de ajudar na produção com os pais e deitou novamente, acordando com o policial lhe chamando, o policial Sentili, que o acordou com um tapa nas costas para que mostrasse onde estava a droga. Não sabia da denúncia anônima ainda. Perguntaram se tinha droga dentro da casa e o interrogado disse que não. O policial disse que se tivesse droga na casa levariam os pais do interrogado presos. Perguntou porque os policiais estavam ali eles disseram que havia uma denúncia anônima. Perguntou se eles tinham mandado e neste momento foi repreendido por um tapa no peito dado pelo referido policial que lhe perguntou se

tinha mais droga no fundo do terreno e o interrogado confirmou. Já tinham revistado a casa inteira. Mandaram o interrogado sentar. Disse que poderia mostrar aos policiais onde estava a droga nos fundos do terreno onde foi com os policiais. Tinha acabado de esconder a droga no local quando chegou da casa da namorada. O pai do interrogado já estava nos fundos com um dos policiais. Nesse momento o policial também disse que tinha denúncia de uma arma. Disse que não tinha mais droga e pediu que os policiais o levassem logo para pouparem seus pais. Então referido policial acionou o canil. Já haviam 06 policiais em casa e chegaram mais 02 policiais com o canil. Em nenhum momento confessou que estava pegando droga para vender. Chegando lá na frente da casa o algemaram. Não tinham o algemado até então. Ameaçaram e agrediram o interrogado. Levaram o pai do interrogado para frente e a mãe do interrogado ajudou os policiais a procurarem droga nos terrenos vizinhos. Quando chegou outro policial perguntando da arma e o interrogado disse que não tinha mais nada além do que já tinham achado. Se despediu dos pais e foi conduzido. Na delegacia prestou um depoimento falando que vendia droga, mas como ainda não tinha passado por uma situação dessa não sabia o que falar porque o delegado já chegou falando ao interrogado que era bastante droga para ser só usuário. Falou que estava vendendo mas em nenhum momento disse que o motivo era para tirar CNH. Na delegacia não foi ameaçado quando interrogado. Foi ameaçado pelos policiais dentro de casa e não confessou nada informalmente para eles. Faziam 02 dias que tinha comprado a droga em Andirá onde o fornecedor deixou no local e mandou mensagem para o interrogado ir buscar. Pagou R\$ 700,00 pela cocaína, R\$ 7,00 cada porção e R\$ 3,00 cada porção de maconha. A droga sempre esteve com o depoente até o momento que foi para casa. Chegou de Andirá na quarta-feira e ficou na casa da namorada até sexta-feira e apenas usava a droga lá. A droga não estava enterrada, mas apenas debaixo de umas folhas e não imaginava uma denúncia anônima desse jeito porque os únicos que sabiam da droga era o interrogado e sua namorada. No dia que foi preso já tinha usado algumas porções de maconha e cocaína, inclusive no mesmo dia da prisão. Quer mais uma oportunidade para se recuperar e sair dessa vida vendo a situação que está colocando sua família. Além da droga foi apreendido apenas o aparelho celular do acusado" (p. 147).

Pelo que precede e por tudo mais que consta dos autos, a condenação é de rigor, já que o réu, apesar de ter negado a traficância em juízo, confessou parcialmente os fatos, confirmando que as drogas eram de sua propriedade e que as mantinha em depósito, porém que eram para seu uso, e tal confissão parcial veio corroborada pela prova oral em juízo, que de resto se verifica consistente e em harmonia com o conjunto probatório.

O réu, embora tenha negado em juízo que a droga seria para venda, em sede policial, acompanhado de seu advogado, confessou a traficância, dizendo que iria vender a droga para levantar um dinheiro para tirar sua CNH e inclusive nomeou a pessoa de quem a comprou como sendo um indivíduo de alcunha "Valmir" e indicou a cidade onde adquiriu os entorpecentes, qual seja, Andirá, no Paraná (p. 04), o que corrobora ainda mais a prova oral colhida em juízo, dando por certa a autoria e materialidade do crime, comprovando a conduta do réu que mantinha em depósito, na sua residência, grande quantidade da substância entorpecente, destinada ao consumo de terceiros. Ademais, trata-se de crime múltiplo e conduta variada, de sorte que basta a realização de um dos verbos para tipificar a conduta criminosa, no caso, "ter em depósito", sendo suficiente a presença do dolo genérico, bastando, assim, que a pessoa guarde consigo a substância "sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar", desde que o propósito não seja para consumo próprio, o que não é o caso dos autos, pois, em que pese ter o réu alegado em seu interrogatório que as drogas seriam para seu uso próprio, certo é que a grande quantidade de drogas apreendidas e a variedade das drogas indicam a traficância, mormente pelo fato dos policiais militares terem recebido denúncia anônima de tráfico de drogas que estaria ocorrendo na residência do réu, conforme depoimentos dos milicianos em juízo.

No mais, não há que se falar em prova ilícita porque se trata de prova produzida a partir de flagrante regular, homologado judicialmente, como já decidido no recebimento da denúncia.

Com efeito, haviam notícias por parte dos moradores do bairro informando aos policiais sobre a prática do tráfico no local, o que se restou foi confirmado pelos policiais militares durante a apreensão das drogas na residência e a confissão informal do réu aos milicianos, justificando a situação de flagrância. Portanto, o conjunto probatório, demonstrando a conduta do réu e as circunstâncias do fato, é suficiente para a sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecente, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena conforme sistema trifásico, do art. 59 e art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais (p. 33-36 e 178-179). Contudo, atento ao disposto no art. 42, da Lei 11.363/06, observo que a natureza e diversidade da droga, maconha e cocaína, indicam maior reprovabilidade da conduta do acusado, mormente considerando o maior grau de nocividade do entorpecente em relação à cocaína, o que autoriza a exasperação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 666 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes. A confissão parcial ou qualificada, desde que influenciada o convencimento do juízo, deve ser considerada, conforme orientação pretoriana: "A confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida, de modo a ensejar a atenuação da pena, caso haja influenciado o convencimento judicial" (AgRg no AREsp n. 1.019.526/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 15/5/2017). Presente a atenuante da confissão, conforme art. 65, III, "d", do Código Penal, ficando o aumento da fase anterior compensado com atenuante em questão, não podendo a pena, nesta fase, ser reduzida abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ), ficando mantida em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Está presente a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, sendo certo que a simples quantidade e diversidade da droga não é suficiente para afastar a figura do tráfico privilegiado, à míngua de outros elementos que denotem habitualidade delitiva a indicar que o réu seja pessoa dedicada a atividades criminosas como meio de vida ou que seja integrante de organização criminosa.

Nesse sentido é a orientação pretoriana:

"(...) I - A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II - A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa." (RHC 138715, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXPRESSAMENTE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO.

AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE.

REVOLVIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos legais do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006 pelo réu, asseverando não existirem nos autos nenhuma circunstância que evidenciasse dedicação à atividade criminosa. 3. A alteração da conclusão dada pela Instância ordinária - de que não existem elementos concretos indicativos de que faziam os recorrente de organização criminosa ou se dedicariam ao tráfico -, implicaria reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. A aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 constitui direito subjetivo do réu, de sorte que, atendidos os requisitos legais,

mister a aplicação da referida causa redutora de pena, devendo os parâmetros previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 ser utilizados não como óbice à sua concessão, mas como vetoriais norteadoras da fixação do quantum de redução a ser aplicado no caso. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1663688/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/02/2021)

No caso dos autos, tem-se ainda que as testemunhas, policiais militares, confirmam que o réu sequer era conhecido dos meios policiais, desconhecendo a existência de investigações em curso, esclarecendo ainda que o único motivo da abordagem foram as informações recebidas através de um morador do bairro no mesmo dia da prisão, tratando-se, portanto, de fato isolado e esporádico, sem indicativo de que se dedicasse ao crime como meio de vida.

Assim, de rigor a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando-se a expressiva quantidade de drogas, 88 (oitenta e oito) porções de cocaína, pesando 36,94g (trinta e seis gramas e novecentos e quarenta miligramas) e 47 (quarenta e sete) porções de maconha, pesando 75,65g (setenta e cinco gramas e seiscentos e cinquenta miligramas), como circunstâncias que justificam a redução mínima de 1/6, resultando a pena em 04 anos e 02 meses de reclusão, além de 416 dias-multa no valor unitário mínimo legal, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Considerando o montante da pena bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, sendo vedada a substituição por penas restritivas de direito, ausentes os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e CONDENO o réu PERICLES FREITAG BENITEZ como incurso nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena pecuniária de 416 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Concede-se ao réu o direito de recorrer em liberdade, como já se encontra.

Determino a liberação total do celular "Samsung", Lacre nº 00005397, em favor do réu, uma vez que não foi possível comprovar sua ilicitude, conforme laudos de p. 208-218 e ofício de p. 242. Oficie-se à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Nos termos do art. 72, da Lei 11.343/06, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas, na forma do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003.

Transitado em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos após as devidas anotações, com as comunicações e demais cautelas de praxe.

P.I.C.

Candido Mota, 28 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA